

1500104-53.2022.8.26.0613

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: WYLDENSOR MARTINS SOARES

Comarca: São José do Rio Pardo

Foro: Foro de São José do Rio Pardo

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 31/05/2022

... em regime fechado, sem o benefício do tráfico privilegiado.

A defesa, por sua vez, alega que o local é uma boca de fumo e o réu era mero usuário que foi ao local para apenas comprar entorpecente. Com ele, nada foi encontrado e não tinha condições de estar associado ao tráfico. A droga estava em local inacessível ao denunciado. Percebe-se a ausência de qualquer prova de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Pardo

Foro de São José do Rio Pardo

1ª Vara

Praça dos Três Poderes, nº 3, São José do Rio Pardo-SP - cep 13720-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500104-53.2022.8.26.0613 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500104-53.2022.8.26.0613

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2061479/2022 - DEL.SEC.CASA

BRANCA, 23400215 - DEL.SEC.CASA BRANCA, 184/22/200 - DEL.SEC.CASA BRANCA, 2061479 - DEL.SEC.CASA BRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FREDERICO FRANCISCO DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). WYLDENSOR MARTINS SOARES

Vistos.

Trata-se de ação penal em desfavor de Frederico Francisco da Silva, como incurso no

artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, eis que no dia 05 de março de 2022, por volta das 16h40, na Rua Luiz Isidoro Lucatelli, Vila Bela Vista, nesta cidade e comarca, vendia e guardava, para fins de tráfico, 33 (trinta e três) invólucros plásticos contendo cocaína, pesando 18,58 gramas, sem autorização e sem desacordo com determinação legal e regulamentar.

A defensoria pública manifestou-se às págs. 50/51 requerendo a concessão de liberdade provisória do réu. Pedido negado conforme decisão de págs. 53/63.

Prisão em flagrante convertida em Preventiva de Liberdade na decisão de págs. 53/62.

A denúncia de págs. 100/101 veio amparada no Inquérito Policial – Prisão em Flagrante – de págs. 01/43.

O réu foi notificados (págs. 109) alegando provar sua inocência em sede de alegações finais.

A denúncia foi recebida aos 20 de abril de 2022. (págs. 118/120).

Durante referida solenidade foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, bem como foi procedido ao interrogatório dos acusados, conforme termo acostado aos autos e mídia que se encontra arquivada em Cartório e disponível aos interessados.

Na fase do art. 402 do CPP nada foi requerido.

Em sede de alegações finais, o representante do Ministério Público requer a procedência da ação penal, pois o laudo de pgs 150/152 confirma a materialidade. A autoria, o acusado nega. Na Delegacia o acusado preferiu o silêncio. Em Juízo, disse que estava ali apenas pelo desejo de comprar uma pedra de crack. A negativa, todavia, não convence. Ambos os policiais, cientes de que no local ocorre tráfico de drogas, viram o acusado em plena prática de traficância. Ele se dirigia a um trilho e pegava algo. Encontraram uma cédula de R\$ 10,00 com o réu. Os policiais encontraram as 33 porções de cocaína e R\$ 60,00 em dinheiro. Nada indica que os policiais querem incriminar injustamente o acusado com o simples propósito de mantê-lo encarcerado. O acusado não trouxe qualquer informação que fizesse desmerecer a versão apresentada em juízo. Ele tem maus antecedentes e é contumaz usuário de droga, o que indica conduta social negativa, também justificando a majoração da pena. Ele é reincidente específico, conforme pgs. 26/30. Deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, sem o benefício do tráfico privilegiado.

A defesa, por sua vez, alega que o local é uma boca de fumo e o réu era mero usuário que foi ao local para apenas comprar entorpecente. Com ele, nada foi encontrado e não tinha condições de estar associado ao tráfico. A droga estava em local inacessível ao denunciado. Percebe-se a ausência de qualquer prova de que o réu tivesse a intenção de vender a droga encontrada no local do crime. O réu nega que estivesse traficando. Diante da insuficiência de provas não há como imputar o denunciado a prática de traficância. É mero usuário e não concorreu com a prática do crime constante na denúncia. Invoca o benefício da dúvida. O réu não foi encontrado em atividade de traficância. Diante da insuficiência probatória, a pretensão punitiva merece ser julgada improcedente.

\*\*\*\*\*

DECIDO.

1 - ) SÍNTESE PROBATÓRIA

2.1 - ) Das provas da materialidade.

A materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão do inquérito policial (págs. 08/09), auto de constatação preliminar (págs. 10), além do exame químico-toxicológico de pgs. 150/152, que indica que a massa líquida da substância foi de 2,7 gramas.

Houve, pois, modificação do mundo naturalístico pela conduta, restando atendido o princípio da materialização do fato.

\*\*\*\*\*

2.2 - ) Das provas da autoria.

Rivaldo Luciano Tonhão relata que o local é a biqueira do Poste ou da rua 7. Sabendo que o local é ponto de tráfico, começaram a observar a movimentação do réu, vulgo "Fred", conhecido dos meios policiais. Observaram algumas vendas, entre 4 a 5 vendas. Ele foi abordado com R\$ 10,00 e questionado disse que não estava traficando. No monte de terra, onde ele mexia, na moita, achou uma pochete onde havia R\$ 60,00 e 33 pinos. A observação foi feita a 40 a 50 metros. A observação durou cerca de 30 minutos. O local que encontrou os pinos era onde o réu abaixava e pegava algo. Do meio fio da rua onde ele ficava, a moita ficava a uns 5 metros e a uns 10 a 15 metros de onde ele foi abordada. Ele negou tudo e reside no Vale IV. É bem longe. Ele não mora perto. A amásia dele também mora no vale IV. No momento da abordagem estava só o réu.

João Paulo Gonçalves Parra disse que viram o réu traficando e tiveram certeza pelo boné e camisa que ele usava. Ele fazia movimentação típica de traficância. Ele já é conhecido dos meios policiais. Ele negou a propriedade. O local é a biqueira da rua 7 ou a biqueira do Poste, locais de conhecida traficância. O réu não aparentava que estivesse sob efeito de entorpecentes. Ficaram observando a uma distância de 50 metros. Ficaram pouco tempo no local, 30 minutos, no máximo. Ele "servia" as pessoas umas cinco vezes. Viu onde o Rivaldo encontrou a droga e era exatamente no local em que o réu se dirigia para pegar algo e entregar.

O réu Frederico Francisco da Silva, falou com seu advogado e está normal da cadeia. Tem 32 anos. Trabalha como auxiliar geral e seu irmão é pintor e trabalha com ele às vezes. É amasiado. Usa crack. Estava usando todo dia, frequentemente. Não chegou a ser internado. A abordagem dos policiais aconteceu sim. Fazia uns 20 minutos que tinha chegado ali. Mora do outro lado do bairro. Tinha ido fumar uma pedra de crack porque ali tinha a pedra maior e melhor. Chegou lá e não tinha o crack. Ofereceu para um moleque um boné da Lacoste e R\$ 10,00. Ficou esperando ali uns 20 minutos. O moleque lhe devolveu os objetos e falou que depois, se quisesse, aceitaria o boné e R\$ 10,00 em troca de crack. Sua amásia estava lhe ajudando a sair do crack. Na abordagem, chegaram uns menores correndo. O depoente ficou lá porque não tinha nada

e só tinha ido buscar a pedra de crack. Só viu os pinos na delegacia de Casa Branca. O Rivaldo foi na parte de trás da moto e colocou não sabe o que lá dentro. Eles chamaram outras viaturas. Os pinos não eram seus. Os moleques correram e não sabe se eles dispensaram não. Gostaria de pedir uma ajuda porque ficou 7 anos e 4 meses preso da outra vez por causa do maldito vício e gostaria de pedir ajuda. Estava em liberdade e se afundou no crack de novo.

\*\*\*\*\*

## 2 - ) DA ANÁLISE CRÍTICA E DO DIREITO APLICÁVEL

Ab initio, é preciso consignar a validade do testemunho policial, pois “goza de presunção de credibilidade”.

Quanto às falas dessas testemunhas, à guisa de ter o agente atuado no feito, tenho por oportuno destacar a sua aproveitabilidade, tanto como a de qualquer pessoa. É que o depoimento do policial, em razão de sua condição de agente da Administração Pública, presume-se verdadeiro e merece crédito, mormente porque se mostra firme, coeso e em consonância com o conjunto probatório dos autos. Tal presunção, obviamente, admitiria prova em contrário, que, entretanto, não foi produzida pela defesa.

A credibilidade do depoimento de policiais tem tanta força quanto a de outros indivíduos. O fato de que cabe a eles a atribuição de prevenir e reprimir o crime não tem o condão de invalidar, de per si, a prova decorrente de seus testemunhos. Por mero preconceito ou suspeita infundada, não deve o Estado-Juiz entender tais depoimentos imprestáveis para lastrear sentença condenatória. O depoimento policial tem plena força probatória, se não houver nenhuma razão plausível, cabalmente comprovada nos autos, para se lhe retirar a credibilidade.

Preceitua o artigo 202 do CPP que “toda pessoa pode ser testemunha”, logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles os autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar, sob compromisso de dizer a verdade e, assim, sujeitos às penas do crime de falso testemunho. Além disso, desconsiderar a validade probatória de um depoimento levando-se em conta, apenas, a profissão de uma pessoa (por exemplo: policial militar ou civil), nada mais é do que tratamento violador do princípio da igualdade, postura essa temerária ao direito.

O escólio pretoriano bem elucida a questão:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (STF – 1ª Turma – HC 74.608-0/SP – Rel. Min. Celso de Mello – DJU de 11.04.97, pág. 12.189).

“A SIMPLES CONDIÇÃO DE POLICIAL NÃO TORNA A TESTEMUNHA IMPEDIDA OU SUSPEITA – STF, RTJ 68/64 E 168/199” (Damásio E. de Jesus, Código de Processo Penal Anotado, Saraiva, 19ª Edição, 2002, p. 176 e 182).

Ainda nesse sentido:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.

INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático-probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. (...) Ordem denegada." (HC 87662, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ 16-02-2007 PP-00048 EMENT VOL-02264-02 PP-00280 LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 417-421). (grifos meus)

Outrossim, é de se ter em conta que se tratando de tráfico de entorpecentes, opera-se a "lei do silêncio", extremamente difícil arrolar testemunhas dispostas a testemunhar contra traficantes.

A perfeita identidade entre as versões, tal como se vê em solo policial e depois em Juízo, é reconhecida pela jurisprudência como fator hábil a dar validade à prova testemunhal policial.

Nada de concreto indica que os policiais estejam injustamente elucubrando versão incriminatória para prejudicar o réu. Noutras palavras, ausentes provas de que os policiais militares estejam mancomunados e imbuídos de sentimentos subalternos dignos de censura a fim de em falso testemunho legitimarem condenação contra inocente.

Por outro lado, em que pese a presunção de inocência e a possibilidade dogmática de incidência do benefício da dúvida é preciso lembrar que o artigo 156 do Código de Processo Penal é categórico no sentido de que "A prova da alegação incumbirá a quem a fizer".

Inexistente contraprova hábil a desqualificar a prova acusatória, o Juízo deve orientar-se pela verdade processual objetivamente existente no processo, sem margem para decisionismo ou dúvida subjetiva. A dúvida deve estar alicerçada na insuficiência de provas ou na existência de provas com versões conflitantes, antagônicas.

Não é possível externar convicção motivada a partir de ilações particulares do julgador, pois a motivação jurídica decorre do processo de persuasão racional, assim entendido como aquele que pode ser devidamente explicado com base nos elementos presentes no processo e não no âmago psicológico da entidade decidente.

Nesse sentido, os ensinamentos de FRAMARINO DEIMALATESTA, o qual afirma que "o princípio ontológico coloca o ônus de prova a cargo da acusação, quando considera as duas asserções contrárias, do acusador e acusado, antes da produção de provas. Mas, desde o momento em que o acusador reuniu as suas provas para sustentar a sua asserção, se o acusado, em contradição à asserção do acusador, emite simples asserção contrária, não faz mais que contrapor uma asserção não provada a uma provada e como esta tem direito de ser tomada como verdadeira de preferência a não provada, sendo a presunção da verdade, neste segundo momento, a favor do acusador, a obrigação da prova incumbe ao acusado" (A Lógica das Provas em Matéria Criminal, Campinas: Conan 1995 v. I p. 45-146 destaque do Juízo)

As alegações defensivas de insuficiência de provas não ecoam no espírito deste julgador a ponto de que o fiel da balança incline-se no sentido oposto à pretensão ministerial.

Destarte, não há campo para desclassificação da conduta para os moldes do art. 28 da Lei de Drogas, tampouco para absolvição do réu, pois ambos os policiais empenhados na diligência são experientes e sabem discernir atos de entrega de drogas ao consumo de terceiros ou a simples permanência no grupo de usuários que frequentam aquela conhecida "biqueira".

No que tange à alegada drogadição, é sabido que a condição de usuário não é incompatível com a traficância. Noutras palavras, "Ainda que admissível a circunstância de que o réu padeça de toxicomania, a alegação de ser usuário de droga tem-se que em nada modifica a imputação, pois perfeitamente conhecida a figurado viciado-traficante" (STF-2ªTurma, HC-MC73.197/GO, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ22.11.1996).

Sobre a questão já se manifestou a Colenda Corte Paulista: - "A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP HC 42.229-3 Rel. Onei Raphael RJTJSP101/498).

Presente a tipicidade delitiva na forma imputada na denúncia e não havendo justificativas ou dirimentes capazes de afastar a antijuridicidade da conduta e culpabilidade do réu, a condenação é medida necessária para a concretização dos escopos de prevenção geral positiva e prevenção especial colimados pelo sistema punitivo, além de restabelecer o princípio da prevalência do Direito e atestar a vigência da norma penal violada.

\*\*\*\*\*

Ex positis, JULGO PROCEDENTE a denúncia de págs. 100/101 com o aditamento feito em audiência para correção de erro material no ano do delito, para CONDENAR FREDERICO FRANCISCO DA SILVA pela prática do crime capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, passando a dosar-lhe as penas, nos termos do artigo 68 do Código Penal e artigo 42 da Lei de Drogas.

Analisadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/2006, observa-se que o modus operandi não recomenda que seja acentuada a pena, pois a culpabilidade é normal à espécie.

Poucos elementos foram coletados acerca de sua conduta social e personalidade, razão pela qual não influenciam negativamente a dosimetria. Além disso, deixo transparecer que tais circunstâncias judiciais se analisadas em detrimento do réu evidenciam acolhimento do "direito penal de autor", fenômeno indesejável e antigarantista que não conta com o aval deste Juízo. Inconvincente o argumento ministerial de que o fato de o réu ser usuário de drogas contumaz deva resultar acréscimo de pena, pois nem mesmo se condenado por prática do crime do art. 28 da Lei de Drogas, pena privativa de liberdade alguma lhe seria imposta. Seria claro contrassenso agravar a pena em 1 dia sequer, quando se condenado por aquele delito o réu não experimentaria tal consequência.

Cabe ressaltar, ainda, a exasperação também não é medida a se impor, neste caso, em relação à natureza das drogas. Crack, cocaína e maconha são entorpecentes considerados "comuns" encontrados em qualquer cidade e apreendidos com frequência diária em São José do Rio Pardo.

A interpretação da Lei Penal exige que este Juízo considere que apenas substâncias

excepcionais como ópio, LSD, ecstasy, heroína, poderiam justificar a majoração da pena com base na natureza do entorpecente.

No entanto, o critério "quantidade" compreende duas variáveis:

1ª O peso, massa, das substâncias propriamente ditas não recomenda acréscimo, pois a apreensão foi de 2,7 gramas, conforme pgs. 151.

2ª A diversidade, variedade das substâncias, pois em "quantidade" de drogas podemos ter pequenas ou grandes porções de 1,2,3 ou mais drogas diferentes.

Analisando os itens o Juízo não encontra campo para acréscimo, uma vez que a quantidade apreendida está dentro dos padrões das apreensões normais e corriqueiras nesta comarca.

O motivo do delito está albergado na própria tipicidade da traficância enquanto atividade mercantil para obtenção de lucro ilícito.

As circunstâncias do delito não destoam daquelas em que ocorrem crimes desta natureza, ao passo que não há elementos para aferir se as consequências foram graves.

O réu ostenta maus antecedentes, pois condenado definitivamente nos autos do processo » Foro de São João da Boa Vista – 1ª Vara. Ação penal – Procedimento Especial da Lei Antitóxicos: 0002799-79.2011.8.26.0568 (0002799-79.2011.8.26.0568) – trânsito em julgado para o réu em 02.05.2012 – pg. 27.

À luz dessas circunstâncias é que fixo a pena-base para o crime capitulado no artigo 33, caput da Lei 11.343/2006, na proporção de 1/6 acima do mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 dias-multa.

O réu é reincidente específico. Além da condenação supra também foi condenado definitivamente nos autos dos processos » Foro de São José do Rio Pardo – 1ª Vara. Ação Penal – Procedimento Ordinário: 3000679-19.2013.8.26.0575 – trânsito em julgado em 14.06.2016, » Foro de São José do Rio Pardo – 1ª Vara. Ação Penal – Procedimento Ordinário: 0002463-48.2014.8.26.0575 – trânsito em julgado em 18.07.2018, » Foro de São José do Rio Pardo – 1ª Vara. Ação Penal – Procedimento Ordinário: 0003496-73.2014.8.26.0575 – trânsito em Julgado em 03.10.2017.

Assim, novo acréscimo se impõe a fim de que a pena seja alçada ao patamar de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Descabida a minorante do § 4º do art. 33 diante dos maus antecedentes e reincidência.

À míngua de outras causas de diminuição ou aumento de pena torno em DEFINITIVA apenas de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Quanto ao regime prisional deve ser o inicialmente FECHADO, pois mantido o caráter hediondo da conduta. Além disso, o réu é reincidente, ostenta maus antecedentes, tendo experimentado condenação no mesmo regime e não se ressocializou. Destarte, a imposição de regime menos rigoroso mostra-se claramente inadequada ao perfil do réu.

Não permito que o réu recorra em liberdade, pois respondeu ao processo preso e após regular instrução fortaleceram-se os indícios de autoria. Nota-se, ainda, tratar-se

de indivíduo que vem cometendo diversos crimes em curto espaço de tempo, os tentando razoável coeficiente de periculosidade.

Nos termos dos artigos 804 e 805 do CPP, CONDENO o réu ao pagamento das custas processuais que fixo em 100 UFESP's. Ressalte-se que o réu está patrocinado por advogado dativo. Assim, defiro-lhe os benefícios da assistência judiciária, ficando a cobrança suspensa na formado § 3º do art. 98 do NCPC c.c art. 3º do CPP.

Patrocinado por advogado dativo, honorários na forma do convênio OAB-DPE.

Saliento que "A condição de beneficiário da Justiça Gratuita não isenta o condenado do pagamento das custas. Eventual isenção poderá ser avaliada à época da execução da sentença condenatória, quando serão apreciadas as reais condições quanto ao estado de pobreza do réu e à possibilidade do pagamento das custas processuais sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. Precedentes. Recurso desprovido, nos termos do voto do relator" (STJ, REsp 343.689/MG, Rel. Min. Gilson Dipp, T5, DJ22. 04.03, p. 253).

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as seguintes providências:

Expeça-se guia de execução definitiva;

Proceda-se ao recolhimento dos valores atribuído a título de pena pecuniária, em conformidade com o disposto no artigo 686 do Código de Processo Penal;

Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia desta decisão, para cumprimento do disposto nos artigos 71, § 2º do Código Eleitoral c/c inciso III do artigo 15 da Constituição da República;

Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais deste Estado para as anotações necessárias;

Decreto o perdimento dos valores apreendidos, pois à míngua de comprovação de origem lícita estão claramente vinculados à mercancia de entorpecentes ilegal desempenhada pelo réu.

Nos termos do art. 72 da Lei de Drogas, proceda-se à destruição do entorpecente mantido para fins de contraprova.

P.I.C.

Sao Jose do Rio Pardo, 31 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA